

1503899-90.2019.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503899-90.2019.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503899-90.2019.8.26.0510 - 2019/000945

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIA LARYSSA FERREIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

ANTONIA LARYSSA FERREIRA DA SILVA, qualificada no inquérito, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 16:20 horas, na Avenida 27, nº 100, Vila Santo Antônio, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, vendeu 02 (dois) microtubos do tipo eppendorf, contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 0,3 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, e laudos de constatação preliminar de fls. 19/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Regularmente notificada, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor da acusada, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 13 de janeiro de 2020. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório da acusada. Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da

prova produzida, requereu a condenação da acusada, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixado o regime aberto. Requereu, por fim, a decretação do perdimento da quantia de vinte reais, decorrente do exercício da atividade ilícita.

Já a ilustre Defensora Pública, inicialmente sustentando atípica a conduta, dada a quantidade irrisória de entorpecente apreendido, requereu a absolvição da acusada, nos termos do disposto no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Assim não se entendendo, porquanto frágil a prova produzida, requereu a absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Em caso de condenação, requereu seja a pena-base fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade, bem assim da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, importando na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, anotando-se regime prisional aberto, facultando-se, por fim, a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se à acusada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, vendeu o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 59/61, com resultado positivo para cocaína.

Sustenta-se, entretanto, que a conduta seria atípica, data a quantidade irrisória de entorpecente apreendida.

No entanto, respeitado o entendimento exposto, além de não ser insignificante a quantidade de entorpecente apreendido, tanto que estava sendo objeto de comercialização, cuida-se de delito (tráfico ilícito de entorpecentes) que implica em violação de bem juridicamente relevante, consistente na segurança e saúde pública, a ponto de ser equiparado a outros delitos de natureza hedionda.

A propósito: "CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 2. O reconhecimento da atipicidade da conduta delitativa com fundamento no princípio da insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, pois trata-se de crime de perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida.

Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 318.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)".

De outra parte, controverte-se sobre a posse do entorpecente apreendido.

Ouvida em juízo, a acusada negou a prática do delito, observando que na ocasião dos fatos, logo após ter deixado a moradia, avistou uma usuária de entorpecente mantendo contato com um indivíduo que se utilizava de uma bicicleta, reconhecendo que por lá ocorre o comércio ilícito. No momento em que, ainda segundo o exposto, aquele indivíduo se afastou, policiais militares se aproximaram, tendo aquela usuária a apontado como sendo a pessoa que lhe teria fornecido as duas porções de cocaína, seguindo-se a apreensão de certa quantia em dinheiro no interior de sua moradia, que dizia respeito à prática de umbanda.

Todavia, a versão deduzida pela acusada, foi contrariada pela prova produzida.

De fato, os Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, reiterando o que exposto na fase inquisitória, afirmaram

em juízo que estavam em patrulhamento pelo local, já muito conhecido como ponto de venda de entorpecente, quando avistaram claramente a acusada mantendo contato com uma usuária, entregando-lhe as duas porções de cocaína, que foram em seguida apreendidas, além da quantia de vinte reais, destinada ao pagamento do entorpecente. Acrescentaram os policiais militares que a usuária confirmou que naquele momento estava adquirindo a droga, enquanto que a acusada igualmente reconheceu que realizava a venda, por isto seguindo-se uma busca no interior da moradia dela, cujo ingresso foi facultado pelo genitor, com a apreensão da quantia de trezentos e dez reais em dinheiro, que se disse decorrente da prática de umbanda.

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829). Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Não obstante as circunstâncias indicadas e a idoneidade do depoimento dos policiais militares, ajusta-se a este conjunto probatório o que declarado, conquanto somente na fase inquisitória, pela referida usuária, na ocasião dos fatos, esclarecendo que estava efetivamente adquirindo o entorpecente da acusada.

Deste modo, tem-se por evidenciada não apenas a posse do entorpecente, mas também a sua destinação mercantil, surpreendida a acusada no próprio ato de mercancia, a possibilitar seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial, incidindo sobre a quantia em dinheiro apreendida com o entorpecente a pena de perdimento. Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de considerar a circunstância atenuante da menoridade, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Deve pena-base cominada, entretanto, ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. É que este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito.

A acusado é primária, não ostenta condenação criminal anterior -- conta com condenação posterior pela prática do delito previsto no artigo 35, da Lei de Tóxicos --, não havendo indicação suficiente, por ocasião dos fatos, de que estivesse já dedicada à atividade criminosa, de tal modo que, também em função da

pouca quantidade de entorpecente, deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica da acusada.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO a acusada ANTONIA LARYSSA FERREIRA DA SILVA à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo, operando-se ainda o perdimento tão somente da quantia apreendida com o entorpecente em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06. Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA